

1501740-93.2021.8.26.0482

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Antonio Roberto Sylla

Comarca: Presidente Prudente

Foro: Foro de Presidente Prudente

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/05/2022

... o acolhimento da acusação de tráfico contra o réu.

Em casos semelhantes, o E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, já decidiu: "Tráfico de drogas - Fragilidade da prova referente à destinação do entorpecente ao comércio - Desclassificação para posse de drogas em razão da comprovação da apreensão do entorpecente em poder do apelante - Inteligência do art. 28, da Lei ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Presidente Prudente

Foro de Presidente Prudente

1ª Vara Criminal

Av. Cel. José Soares Marcondes. 2201, Presidente Prudente - SP - cep 19013-050

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1501740-93.2021.8.26.0482 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501740-93.2021.8.26.0482

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MATHEUS MARQUES ROSA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Antonio Roberto Sylla

Vistos.

Trata-se de ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO contra MATHEUS MARQUES ROSA, qualificado à fl. 11, imputando-lhe a prática do crime descrito nos artigos 33, "caput", ambos da Lei nº 11.343/06, porque, segundo a denúncia:

"Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 23 de abril de 2021, por volta das 23h00, na Rua Visconde de Cairu, Vila Comercial, nesta cidade e Comarca de Presidente Prudente/SP, MATHEUS MARQUES ROSA trazia consigo 17 pedras de crack (cocaína), totalizando 1,36g (um grama e trinta e seis centigramas) da substância ilícita, destinadas à comercialização, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 07/08 e laudos periciais de fls. 24/26 e 35/37. Na data, hora e local supramencionados, policiais militares avistaram o denunciado em atitude suspeita próximo ao terminal rodoviário e tentaram abordá-lo, mas ele empreendeu fuga. O denunciado foi encontrado na Praça dos Pioneiros e tentou fugir novamente, mas os policiais conseguiram detê-lo. MATHEUS carregava 01 (uma) caixa de cigarro

contendo resquícios de cocaína e trazia consigo 17 (dezessete) pedras de crack, R\$ 71,20 (setenta e um reais e vinte centavos) em dinheiro, além de telefone celular e relógio de pulso, que foram devidamente apreendidos (auto de apreensão/exibição a fls. 07/08). Os laudos periciais de fls. 24/26 e 35/37 constataram a presença de cocaína na caixa de papelão e nas 17 pedras de crack apreendidas. As circunstâncias em que se deram os fatos, somadas à quantidade de drogas apreendida, a forma como a porção estava dividida e armazenada, além da quantia em dinheiro localizada, relacionados a comércio de entorpecentes, afigura-se quadro seguro a apontar que a droga seria destinada ao tráfico ilícito de entorpecentes.". Acompanha a denúncia o respectivo inquérito policial.

Após regular citação apresentado defesa preliminar (fls. 99/100), sobre a qual o Ministério Público se manifestou (fls. 104), o despacho de fls. 105/108, de 4 de novembro de 2021, recebeu a denúncia e determinou a produção de provas.

Em alegações finais, o nobre Dr. Promotor de Justiça (fls. 206), pediu a parcial procedência da ação penal, com a desclassificação da conduta anteriormente imputada para o delito do artigo 28, da Lei nº 11.343/06. Por sua vez, o ilustre Dr. Defensor Público (fls. 206), arguiu em face da manifestação do Ministério Público, e ausente os elementos constitutivo do tráfico de drogas, requer a absolvição do réu, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para o crime de porte de drogas para consumo pessoal.

É o relatório.

DECIDO.

Inicialmente, verifica-se que nenhuma nulidade há, eis que o processo tramitou de forma regular, sendo respeitados todos os preceitos legais e não havendo preliminares arguidas.

Passo à análise do mérito.

Para que se possa cogitar em condenação no âmbito criminal, os fatos descritos devem necessariamente corresponder a um tipo penal previsto em lei incriminadora vigente à época da conduta apurada. Além disso, a acusação deve comprovar, mediante provas robustas colhidas na esfera judicial, os critérios de autoria e materialidade, para todos os crimes apontados na denúncia.

A materialidade dos fatos narrados na denúncia e imputados ao réu, encontra-se suficientemente demonstrada nos autos pelo auto de exibição e apreensão de fls.

7/8; pelo laudo químico toxicológico de fls. 35/37, atestando - Item Único (Acondicionado sob o lacre 0035233 ) Descrição: 1 (uma) porção de material sólido petrificado, de cor bege. Massa Bruta e/ou Quantidade: 6,49 grama(s) - seis gramas e quarenta e nove centigramas. Massa Líquida: 1,36 grama(s) - um grama e trinta e seis centigramas. Resultado: A análise do material descrito fez o uso de Cromatografia em camada delgada e foi DETECTADA presença da substância COCAÍNA, constante na lista F1 da Portaria SVS/MS 344/98 e atualizações posteriores (Portaria SPTC 136 de 03/08/2020); Laudo pericial de objetos de fls. 24/26 que analisou - Item Único (Acondicionado sob o lacre 0015789) Descrição: 01 (uma) caixa na forma de paralelepípedo, confeccionado por papelão, usada, articulável, contendo em suas superfícies inscrições diversas, tais como, "SAN MARINO", "AMERICAN BLEND", e também ilustrações de cigarros. Resultado: A análise do material descrito fez o uso de Cromatografia Gasosa acoplada à Espectrometria de Massas e foi DETECTADA presença da substância COCAÍNA, constante na lista F1 da Portaria SVS/MS 344/98 e atualizações posteriores (Portaria SPTC 136 de 03/08/2020); pelo laudo pericial no aparelho celular de fls. 58/64; além da prova oral carreada para os autos.

Em Juízo, o PM Anderson Luis Dalaqua, sob o crivo do contraditório declarou que estava em patrulhamento e nas proximidades da rodoviária, avistaram dois indivíduos que dava a impressão que um passada algo para o outro pelas mãos, e ao avistarem a viatura, empreenderam fuga. Fizeram a volta e voltaram na praça dos pioneiros e onde estavam sentados dessa vez, e um dos indivíduos ao perceber saiu correndo, mas caiu, sua parceira desembarcou da viatura e o perseguiu conseguindo alcança-lo, fez a volta com a viatura conseguindo aborda-lo. Em revista pessoa foi encontrado uma quantia em dinheiro, um maço de cigarro, dentro deste tinha uma nota de dinheiro e umas pedras de crack envolvida nesse dinheiro. O réu disse que as drogas eram para

consumo pessoal. Não conhecia o réu anteriormente.

A testemunha PM. Jacqueline Silva de Souza Braga, sob o crivo do contraditório declarou que faziam o patrulhamento pela praça e na tentativa de abordar o Matheus, ele empreendeu fuga, fizeram o retorno, e conseguiram aborda-lo, mesmo que tenha empreendido fuga novamente, mas conseguiram aborda-lo. O réu estava com outra pessoa, não identificada. Visualizou que um deles passou algo para o outro, fato que chamou a atenção para fazerem a abordagem. Era o Matheus que fazia a troca de objeto. A outra pessoa não foi abordada, guardou somente a fisionomia do Matheus pois era a encarregada. O réu alegou que era usuário. Sobre o dinheiro não se lembra o que ele disse. Sobre o contrato de menor aprendiz, viu somente na Delegacia, quando teve acesso ao boletim de ocorrência, mas ele não lhe disse nada no momento da abordagem. Não deu para constatar claramente quem passava algo para o outro.

O réu Matheus Marques Rosa localizado e intimado (fls. 205), porém, deixou imotivadamente de comparecer para ser interrogado, sendo decretada a sua revelia (fls. 206).

Perante a autoridade Policial o réu MATHEUS MARQUES ROSA, que é usuário de droga. consumiu muita droga na noite de hoje e estava perto do terminal rodoviário quando uma viatura passou a persegui-lo que realmente correu porque estava com as pedras de crack em seu poder que havia acabado de comprar para seu consumo. Que referente ao seu dinheiro que estava em seu poder e proveniente de seu trabalho como menor aprendiz. que o relógio ganhou de um usuário de droga e o celular não funciona e o mesmo achou. Autoriza o acesso ao aparelho. Que na fuga dos policiais acabou caindo no chão, mas acabou sendo agredido pelos policiais. Informa que os policiais Militares localizaram as pedras de crack em seu poder quando de sua detenção. Que recebe neste ato a requisição de IML. Tem escoriações da queda enquanto tentava a fuga e abordagem, na qual alega que os policiais foram agressivos, tendo recebido requisição IML.

Encerrando-se a instrução processual.

Esse conjunto probatório é insuficiente para demonstrar a prática do tráfico de drogas praticado pelo réu.

O próprio i. representante do Ministério Público reconheceu como não comprovada e pediu a desclassificação da conduta para o delito de porte de drogas para consumo pessoal.

As informações que os policiais trouxeram na fase inquisitiva, não foram suficiente para imputar ao réu a prática do crime de tráfico, mormente pela ação do réu e de outra pessoa não identificada que conseguiu se evadir da ação estatal, no momento em que não puderam afirmar quem passou algo para o outro no momento que chamou a atenção da guarnição da Polícia Militar e ensejou a abordagem, que não se tornam confiáveis a ponto de erigir um decreto condenatório. Ademais, nenhum dos atos de traficância não se mostraram lúcidos a ponto de manter a acusação contra o réu. Por tudo isso e também pelo depoimento do réu na fase inquisitiva, quando disse, enfaticamente, que a droga lhe pertencia, que tinha usado muita droga naquela noite e se assustou com a presença da viatura, já que ainda tinha mais drogas na sua posse.

Essas dúvidas não permitem o acolhimento da acusação de tráfico contra o réu.

Em casos semelhantes, o E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, já decidiu: "Tráfico de drogas - Fragilidade da prova referente à destinação do entorpecente ao comércio - Desclassificação para posse de drogas em razão da comprovação da apreensão do entorpecente em poder do apelante - Inteligência do art. 28, da Lei nº 11.343/06 - Recurso da Defesa parcialmente provido com o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva" (Apelação criminal nº. 0008679-51.2009, Salto, rel. Alexandre Almeida, j. 13.4.2011).

"E, ainda que tivesse o apelante admitido a propriedade da droga, na fase judicial, afirmou que se destinava a consumo próprio, negando o tráfico, o que há de ser recepcionado, pois, em realidade, nenhuma prova se fez em sentido contrário, ou seja, que houvesse o intuito de entrega ou fornecimento a terceiros, mormente se confrontada a conduta assumida com os elementos de convicção trazidos aos autos, não havendo possibilidade, assim, de manter-se, o decreto condenatório, com fulcro

no art. 33 da Lei nº 11.343/06, mesmo porque, ante a gravidade dos fatos deduzidos na inicial e considerado que a resposta penal para o delito imputado é por demais severa, se exige, como manifesto, prova límpida e estreme de dúvida, em relação à autoria do crime de tráfico ilegal de entorpecente; de rigor., portanto, operar a desclassificação" (Apelação Criminal nº 990.09.174232-5, São Paulo, rel. Antonio Manssur, j. 15.12.2010).

"TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE PORTE DE DROGAS PARA USO PRÓPRIO (ARTIGO 28 DA LEI Nº 11.343/06)- POSSIBILIDADE - AUSENTES EVIDÊNCIAS INEQUÍVOCAS DA MERCANCIA. Cabível a desclassificação para o crime de posse de tóxicos para consumo pessoal quando as provas colhidas são frágeis a ensejar condenação por tráfico. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO." (TJ-SP - APL: 00021751520168260322 SP 0002175-15.2016.8.26.0322, Relator: Willian Campos, Data de Julgamento: 08/06/2017, 15ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 12/06/2017).

A apreensão de pequena quantidade de droga, bem como a ausência de demais elementos concretos a demonstrar suspeita de mercancia ilícita de entorpecentes, e a falta de abordagem de suposto adquirente são indicativos de que a droga era para consumo próprio.

Ausente a prova do tráfico, correta a desclassificação da infração para uso próprio. Não é suficiente a probabilidade do cometimento do delito. A dúvida acerca da destinação das drogas apreendidas se revolve em favor do réu.

Desclassificação a imputação que a denúncia faz ao réu para o delito de porte de droga para consumo pessoal.

A subsistência do caráter criminoso da conduta porte de droga para consumo pessoal se justifica pela lesão ao bem jurídico tutelado, qual seja, a incolumidade e saúde públicas.

A lei não pune, contudo, o consumo da droga (se o fizesse o tipo seria inconstitucional); incrimina-se, tão somente, o ato de adquirir, guardar, ter em depósito, transportar ou trazer consigo (para consumo pessoal) drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

E é nessas situações que o comportamento do agente vulnera o bem tutelado na norma incriminadora, tendo em conta as propriedades maléficas da droga e a potencial disseminação desses malefícios na sociedade.

O artigo 28, da Lei 11.343/06, cuida de infração de mera conduta, não se fazendo mister nenhum perigo concreto ao bem jurídico.

Já que trata de mera infração "sui generis", não sendo a prisão a pena cominada, pode-se transigir com as exigências emanadas do princípio da ofensividade (lesão ou perigo concreto de lesão ao bem jurídico).

Tal como ressaltado, a coibição legal do uso de drogas não se destina somente ao usuário, vai além, impede a proliferação dos malefícios das substâncias entorpecentes para a coletividade e para a saúde pública, sendo típica a conduta.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal já decidiu acerca da natureza jurídica da conduta prevista no art. 28, da Lei nº 11.343/06, reconhecendo, por conseguinte, a constitucionalidade da criminalidade do uso de entorpecente, confira-se:

"POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL:(ART. 28 DA L. 11.343/06 - NOVA LEI DE DROGAS): NATUREZA JURÍDICA DE CRIME - 1. O art. 1º da LICP - que se limita a estabelecer um critério que permite distinguir quando se está diante de um crime ou de uma contravenção - não obsta a que Lei ordinária superveniente adote outros critérios gerais de distinção, ou estabeleça para determinado crime - como o fez o art. 28 da L. 11.343/06 - pena diversa da privação ou restrição da liberdade, a qual constitui somente uma das opções constitucionais passíveis de adoção pela Lei incriminadora (CF/88, art. 5º, XLVI e XLVII). 2. Não se pode, na interpretação da L.11.343/06, partir de um pressuposto despreço do legislador pelo "rigor técnico", que o teria levado inadvertidamente a incluir as infrações relativas ao usuário de drogas em um capítulo denominado "Dos Crimes e das Penas", só a ele referentes.

(L.11.343/06, Título III, Capítulo III, arts. 27/30). 3. Ao USO da expressão "reincidência", também não se pode emprestar um sentido "popular", especialmente porque, em linha de princípio, somente disposição expressa em contrário na L. 11.343/06 afastaria a regra geral do C. Penal (C. Penal, art. 12). 4. Soma-se a

tudo a previsão, como regra geral, ao processo de infrações atribuídas ao usuário de drogas, do rito estabelecido para os crimes de menor potencial ofensivo, possibilitando até mesmo a proposta de aplicação imediata da pena de que trata o art. 76 da L. 9.099/95 (art. 48, §§ 1º e 5º), bem como a disciplina da prescrição segundo as regras do art. 107 e seguintes do C. Penal (L. 11.343, art. 30). 6. Ocorrência, pois, de "despenalização", entendida como exclusão, para o tipo, das penas privativas de liberdade. 7. Questão de ordem resolvida no sentido de que a L. 11.343/06 não implicou abolição criminis (C. Penal, art. 107). II. Prescrição: Consumação, à vista do art. 30 da L. 11.343/06, pelo decurso de mais de 2 anos dos fatos, sem qualquer causa interruptiva. III. Recurso extraordinário julgado prejudicado. (RE-QO 430105 -RJ - 1ª T. - Rel. Min. Sepúlveda Pertence - DJU 27.04.2007).

A reduzida quantidade de drogas integra a própria essência do crime de porte de substância entorpecente para consumo próprio, visto que, do contrário, poder-se-ia estar diante da hipótese do delito de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.

Vale dizer, o tipo previsto no artigo 28 da Lei n. 11.343/2006 esgota-se, simplesmente, no fato de o agente trazer consigo, para uso próprio, qualquer substância entorpecente que possa causar dependência, sendo, por isso mesmo, irrelevante que a quantidade de drogas não produza, concretamente, danos ao bem jurídico tutelado, no caso, a saúde pública ou do próprio indivíduo.

Nesses termos, passo à dosimetria da medida.

Observando os elementos norteadores previstos no artigo 59 do Código Penal e 42 da Lei 11.343/06, fixo a pena em advertência sobre os efeitos das drogas.

ISTO POSTO e o que mais dos autos consta JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal a fim de DESCLASSIFICAR a conduta anteriormente imputada ao réu para aquela prevista no artigo 28, da Lei nº 11.343/06, e CONDENAR o réu MATHEUS MARQUES ROSA, RG: 53363182, nascido em 19/08/2002, filho de TATIANE MARQUES ROSA, a cumprir a pena de advertência sobre os efeitos das drogas, conforme preceitua o artigo 28, inciso I, da Lei nº 11.343/06.

Determino a imediata restituição para o réu do aparelho celular e do numerário apreendidos nos autos.

Condeno o réu a pagar as custas processuais. Porém, atento aos elementos constantes do processo, defiro-lhe a gratuidade da justiça, de modo que a exigibilidade do tributo ficará suspensa enquanto perdurarem os embaraços que justificaram a concessão do benefício. Decorridos cinco anos da sentença final sem que as condições econômicas autorizem a cobrança da taxa, a obrigação estará prescrita. Sentença publicada nesta data, com a liberação nos autos digitais. Dispensa-se o registro, na forma do artigo 72, § 6º, das Normas da Corregedoria Geral de Justiça. Intimem-se.

Presidente Prudente, 27 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA